

1500007-50.2021.8.26.0205

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIS FERNANDO VIAN

Comarca: Getulina

Foro: Foro de Getulina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... e CLAUDIO não estavam lá; que o local é conhecido por tráfico de drogas; que muitos usuários que abordam dizem que comprem drogas de CRISTIANO; que havia denúncias que LUCIANO e CLAUDIO também praticavam tráfico de drogas; que dentro do imóvel não foram encontradas drogas; que encontraram uma balança, um pino vazio e embalagens; que CLÁUDIO morou no imóvel, mas crê que na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Getulina

Foro de Getulina

Vara Única

Rua Dr. Carlos de Campos, 660, . - Centro

CEP: 16450-000 - Getulina - SP

Telefone: (14) 2185-5110 - E-mail: getulina@tjsp.jus.br

1500007-50.2021.8.26.0205 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500007-50.2021.8.26.0205

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO ROQUE DE SOUZA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS FERNANDO VIAN

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de CRISTIANO FERNANDO ROQUE DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; LUCIANO ROQUE DE SOUZA e CLAUDIO ROQUE DE SOUZA como incursos no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal; e CRISTIANO FERNANDO ROQUE DE SOUZA, LUCIANO ROQUE DE SOUZA e CLAUDIO ROQUE DE SOUZA como incursos no artigo 35 da Lei 11.343/06, porque no dia 29 de outubro de 2020, às 7h45, na residência localizada na Rua Odilon Alexandrino, 342, no município de Guaibê/SP e comarca de Getulina/SP, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no artigo 33, caput, e § 1º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, CRISTIANO FERNANDO ROQUE DE SOUZA, vulgo "Burca", trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 120 (cento e vinte) porções de cocaína, acondicionadas em tubos plásticos do tipo "Eppendorf", com peso líquido total da referida substância de 9,24g (nove gramas e vinte e quatro centigramas); uma porção de cocaína petrificada, com peso líquido total da referida substância de 34,65g (trinta e quatro gramas e sessenta e cinco centigramas); uma porção de Cannabis Sativa L (maconha), constituída por folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, com peso líquido total de 41,58g (quarenta e um gramas e cinquenta e oito centigramas), todas substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e

apreensão de fls. 10/11 e laudo de constatação definitivo de fls. 21/23. Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, agindo em concurso e com perfeita unidade de desígnios, LUCIANO ROQUE DE SOUZA, vulgo "Maguila", qualificado a fls. 45, e CLAUDIO ROQUE DE SOUZA, qualificado a fls. 70, consentiram, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que CRISTIANO FERNANDO ROQUE DE SOUZA, já qualificado, se utilizasse do imóvel do qual têm posse para o tráfico ilícito de drogas.

Recebimento de denúncia às fls 173/174 e ratificada às fls 354/358.

Resposta à acusação dos réus às fls 338/343, 377 e 389/390.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 516/518), foram inquiridas as testemunhas comuns Hugo Favero Duarte (fls. 511) e Sidnei Aparecido de Almeida Zeferino (fls. 510) e as testemunhas de defesa Luiz Antonio Salles (fls. 509), arrolada pelo réu Cristiano, e Aparecido de Souza (fls. 508), arrolada pelo réu Cláudio. Posteriormente, foi dito pelo Advogado do acusado Cláudio que dispensava a oitiva da testemunha de defesa Jomar Antônio de Souza, o que contou com a concordância dos demais acusados e do representante do Ministério Público, bem como com homologação do MM. Juiz. A seguir, foram realizados os interrogatórios (fls. 515/513, 514 e 515).

Os debates orais foram convertidos em memoriais escritos.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais às fls 524/533, requerendo a parcial procedência da pretensão punitiva estatal.

O réu Cláudio Roque de Souza apresentou suas alegações finais às fls 549/552, postulando que seja o denunciado absolvido nos termos do art. 386, IV, do CPP. O réu Luciano Roque de Souza apresentou suas alegações finais às fls 557/561, também requerendo a absolvição do denunciado. Cristiano Fernando Roque de Souza apresentou seus memoriais às fls 564/573, requerendo também sua absolvição, por insuficiência probatória.

É o relatório. Passo a decidir.

Não foram aventadas preliminares pela defesa, o feito tramitou regularmente e todas as garantias processuais do acusado foram devidamente observadas ao longo da instrução.

O Ministério Público do Estado de São Paulo imputa aos acusados os crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06; artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal e artigo 35, "caput", também da Lei 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Passo à análise individualizada da conduta de cada um dos réus.

Dos crimes imputados aos réus Cláudio Roque de Souza e Luciano Roque de Souza

A prova da materialidade dos delitos narrados na inicial se mostrou frágil e insuficiente à expedição de um decreto condenatório.

Com efeito, conforme assinalado pelo Ministério Público, o réu Cláudio comprovou que residia em outra cidade na data dos fatos, tendo produzido prova oral de que morava em Júlio Mesquita há anos, fato que também foi confirmado por seus irmãos e corréus, os quais disseram que ele não os visita.

Além disso, comprovou seu álibi, juntando cartão de ponto do dia em que houve a busca e apreensão, que no dia dos fatos estava trabalhando em outro lugar, o que reforça que não residia no imóvel onde ocorre a traficância.

Por outro lado, não há elementos hábeis a concluir que o réu Luciano tenha praticado os crimes que lhe imputa a inicial. Isto porque o simples fato de acusado

residir com seu irmão num imóvel compartilhado não permite que se adote a conclusão de que sabia do tráfico por ele realizado e que consentia acerca da sua prática, sob pena de se adotar uma responsabilidade objetiva em Direito Penal, o que não se admite.

Com efeito, a insuficiência probatória no processo penal, homenageada pela aplicação do princípio do "in dubio pro reo" conduz inexoravelmente à absolvição do indivíduo denunciado quando a acusação não se desincumbira do ônus de comprovas suas alegações.

É dizer: em direito penal a presunção de culpa é afastada pelo princípio constitucional da presunção de inocência, encravado do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal como corolário dos fundamentos vitalícios do Estado Democrático de Direito, sendo traduzido por uma regra de tratamento e de julgamento diante da dúvida sobre o objeto da prova.

No caso dos autos, diante de toda a prova produzida não se conseguiu demonstrar a prática dos delitos pelo acusados Cláudio e Luciano, de modo que sua absolvição é medida que se impõe, na forma do artigo 386, VII.

Dos crimes imputados ao réu Cristiano Fernando Roque de Souza

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6), pelo auto de exibição e apreensão de (fls. 10/11), pelas fotografias das drogas apreendidas (fls. 14/20), pelo laudo de constatação definitivo (fls. 21/23), pelo registro do "Disque Denúncia" (fls. 120/122) e pelo relatório de investigação (fls. 123/131), bem como pela prova oral e demais elementos coligidos nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, senão vejamos.

A testemunha Hugo Favero Duarte, policial civil ouvido na fase de instrução a fls. 511, disse que um "Disque Denúncia" chegou na delegacia, informando que LUCIANO estaria praticando comércio de drogas ilícitas no local dos fatos e após pesquisas com base no endereço constaram que já haviam sido realizadas diversas buscas no mesmo local durante anos, sempre com relação aos três réus, porém infrutíferas; que então empreenderam diligências, como fotografar o imóvel, que fica em uma das extremidades da cidade, constando haver grande movimentação de pessoas e livre circulação em diversos horários, sendo algumas dessas pessoas conhecidas como usuárias de drogas, em que pese não tenham flagrado a mercancia; que no cumprimento da busca e apreensão entrou no imóvel e logo em seguida foi informado de que CRISTIANO estava do lado de fora em via pública e que, ao avistar as viaturas, CRISTIANO fugiu em direção a um pasto que existe no fim da rua; que a Polícia Militar auxiliou no acompanhamento a pé, mas não conseguiram abordar CRISTIANO; que o policial militar Almeida viu que CRISTIANO carregava algo com ele e dispensava conforme corria; que com o uso do cão farejador, previamente solicitado, foi possível localizar essa trilha de "migalhas" deixada por CRISTIANO, até chegar a essa sacola que continha a maior parte do entorpecente apreendido; que no imóvel foi localizada balança de precisão e outros petrechos, além de um pouco de dinheiro; que LUCIANO e CLAUDIO já não estavam no imóvel; que a única pessoa que estava no imóvel era a esposa de LUCIANO, Gabriela, que foi quem acompanhou a busca no imóvel; que posterior a essa apreensão e a instauração de inquérito policial, continuou a chegar informações de que havia traficância no local, dando conta que CRISTIANO, LUCIANO, Daniel, irmão mais novo, e Gabriela, todos residentes do imóvel, estariam ainda praticando o tráfico no mesmo local; que chegaram imagens que sugeriam que CRISTIANO estaria vendendo entorpecentes para indivíduo identificado como Márcio; que após cumprir a busca, tomaram conhecimento de que CLAUDIO já não mais residia ali; que todos os outros residem no mesmo local; que dentro do imóvel foi apreendido um pino, ainda vazio, de mesma cor e características dos outros apreendidos no pasto; que dentro do imóvel não foram encontradas drogas; que não sabia a cidade e o local onde CLAUDIO estaria morando; que não visualizou LUCIANO ou CLAUDIO cometendo ato de traficância; que, com relação à associação para o tráfico, a única informação que havia recebido quanto aos demais irmãos [além de CRISTIANO] era que eles consentiam com o uso do imóvel, tendo colocado em seu relatório que não havia elementos contra eles, salvo essa colaboração; que o imóvel é próprio e a família reside lá há muito tempo já.

A testemunha Sidnei Aparecido de Almeida Zeferino, policial militar ouvido na fase de instrução a fls. 510, disse que sua viatura foi uma das primeiras a chegar ao local e quando CRISTIANO, vulgo "Burca", que estava no portão da frente da casa dele, que fica na lateral do imóvel, viu as viaturas, ele saiu correndo em direção ao pasto; que a casa de CRISTIANO fica no fundo da casa da família, que é tudo da mesma família; que o pasto fica uns trinta, no máximo cinquenta metros da casa dele, local de fácil e rápido acesso da casa dele; que correu atrás dele; que viu que CRISTIANO estava correndo com uma sacola na mão e que ele estava dispensando pinos de cocaína; que CRISTIANO passou por uma cerca e não conseguiu mais vê-lo; que o cachorro do canil encontrou a sacola, que estava perto de onde CRISTIANO sumiu; que LUCIANO e CLAUDIO não estavam lá; que o local é conhecido por tráfico de drogas; que muitos usuários que abordam dizem que comprem drogas de CRISTIANO; que havia denúncias que LUCIANO e CLAUDIO também praticavam tráfico de drogas; que dentro do imóvel não foram encontradas drogas; que encontraram uma balança, um pino vazio e embalagens; que CLAUDIO morou no imóvel, mas crê que na época ele não estava mais lá não; que não sabe há quanto tempo, porque esse pessoal uma hora está lá, outra não está, é muito entra e sai na casa; que já abordou usuários, tais como "Cosminho", "Zé Pé", que nomearam CLAUDIO como vendedor de entorpecentes, não se lembrando do nome deles; que sempre fizeram ronda no local, sempre vendo uns dois ou três por lá; que se falava que os réus escondiam as drogas no pasto.

A testemunha de defesa Luiz Antonio Salles, ouvido na fase de instrução a fls. 509, disse que o réu LUCIANO presta serviços a ele em época de safra de manga, pagando de dois e cinquenta a três reais por caixa colhida; que eram por volta de 300 a 500 caixas por fim de semana.

A testemunha de defesa Aparecido de Souza, ouvido na fase de instrução a fls. 508, disse que conhece CLAUDIO há mais ou menos dez anos e que ele reside perto de sua casa, em Júlio Mesquita/SP, há uns cinco ou seis anos; que no fim de 2020 ele trabalhava em uma empresa de asfalto, na BR entre Cafelândia e Marília, sendo seu horário de trabalho das 7h às 19h, por fazia hora extra; que CLAUDIO teria que sair de casa às 6h da manhã para chegar no trabalho.

Em seu interrogatório (fls. 512/513), CLAUDIO ROQUE DE SOUZA negou os fatos, dizendo que nunca se envolveu com drogas, tendo saído de Guaibê há mais de cinco anos e fixado residência em Júlio Mesquita/SP; que estava registrado em uma firma e não tem nada a ver com os fatos; que não frequentava o local, que não via seus irmãos; que seu irmão CRISTIANO era montador de boi, fazia festas e ganhava prêmios; que seu irmão LUCIANO mexe com gados, trabalha na roça; que juntou sua folha de ponto do dia da apreensão, holerite, carteira registrada.

Em seu interrogatório (fls. 515), LUCIANO ROQUE DE SOUZA negou os fatos, dizendo que mora no local dos fatos, mas nunca viu movimento de drogas em casa; com relação ao pino vazio, disse que sua irmã Kelly, que reside no mesmo local, é dependente de crack; que no dia da busca e apreensão estava trabalhando, tendo recebido uma ligação do delegado e se disposto ir até o local, mas o delegado disse que não precisava; que CRISTIANO mexe com gado, rodeio; que no dia dos fatos houve um desentendimento entre Kelly e CRISTIANO e ele achou que ela tivesse chamado a polícia, por isso ele correu; que o imóvel é de seu pai, que também mora no local; que moram no local seu pai, sua esposa, sua filha, sua irmã e um irmão mais novo, que se casou recentemente.

Em seu interrogatório (fls. 514), CRISTIANO FERNANDO ROQUE DE SOUZA negou os fatos, dizendo que brigou com sua irmã Kelly por volta das 7h30 da manhã e que ela deu um tapa em sua cara, tendo revidado com um soco, momento em que duas viaturas apareceram e fugiu, porque ela disse que mandaria prendê-lo; que a sacola com drogas não é sua, porque não mexe com essas coisas; que o policial está mentido, porque já disse que ia "forjá-lo"; que a polícia chegou por volta das 8h; que voltou para casa por volta de umas seis horas; que mora sozinho com sua esposa e seus dois filhos nos fundos; que LUCIANO mora na outra casa; que CLAUDIO mora em Júlio Mesquita; que CLAUDIO não costuma visitá-lo; que trabalhava na época, mexendo com gado, montando em boi em rodeio.

Pois bem.

Como visto, o presente procedimento teve início através dos trabalhos

investigativos da Polícia Civil, considerando o recebimento de notícia anônima que informava a venda de cocaína e maconha na residência de LUCIANO, sendo que tal atividade tinha a participação de seus irmãos CLAUDIO e CRISTIANO (fls. 120/122). Ao darem cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 1500265- 94.2020.8.26.0205, devidamente autorizado por este Juízo (fls. 41/43) após representação da Autoridade Policial (fls. 34/40), os policiais Hugo Favero e Sidnei Aparecido visualizaram CRISTIANO em um pasto que há no local segurando uma sacola. CRISTIANO, ao avistar a viatura policial, evadiu-se em direção a uma mata, dispersando durante a fuga diversos pinos contendo cocaína e uma porção de maconha, não sendo mais alcançado. Realizadas buscas no pasto por onde CRISTIANO se evadiu, com a ajuda dos cães farejadores da Polícia Militar, foram encontrados pelo trajeto alguns pinos contendo substância amarelada conhecida como crack e, mais adiante, na sacola, foram encontrados outros pinos contendo a mesma substância, além de duas pedras maiores de substância conhecida como crack e algumas porções de maconha.

Como bem ressaltado pelas testemunhas comuns ouvidas em juízo, o local dos fatos já é de conhecimento dos meios policiais como ponto de comércio de entorpecentes ilícitos, tendo a Polícia Civil já deflagrado diversas Operações Policiais com o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos últimos anos, conforme os Boletins de Ocorrência 184/2020, 165/2019, 296/2016, 303/2015, 83/2015, 195/2014, descritos no relatório de investigações de fls. 123/131.

Observo que a narrativa dos policiais apresentou firmeza e coerência, demonstrando que os entorpecentes e demais objetos apreendidos tanto no pasto próximo à residência, quanto na residência se deram em contexto que denotava a prática do crime de tráfico, pois comumente utilizados para esta finalidade.

Considerando ainda que o local é de conhecimento dos meios policiais como ponto de venda de drogas, tendo sido durante anos já diligenciado (o que se comprova pela simples análise dos diversos Boletins de Ocorrência acima mencionados), resta demonstrado também que a prática do tráfico de drogas já se realizava há algum tempo no local.

Acerca da palavra dos policiais militares e de sua credibilidade para formação da convicção do magistrado, a jurisprudência é firme em lhe atribuir valor probatório diante dos demais elementos colhidos no bojo da persecução criminal.

Neste sentido:

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário". (TJSP; Apelação Criminal 1504092-61.2018.8.26.0536; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021).

Some-se a isto o fato de que o réu, ao ser interrogado, confessou os fatos imputados, admitindo a traficância.

Observo que o fato de as drogas não terem sido encontradas dentro do imóvel não afasta a autoria, justamente porque, aliado às prévias denúncias, CRISTIANO foi visto correndo e dispensando drogas, cujos pinos eram da mesma cor e natureza do encontrado vazio dentro da residência, onde também foram localizados a balança e embalagens.

A negativa do réu Cristiano, neste ponto, se revela pouco crível e resta isolada diante do farto conjunto de provas carreado aos autos, não merecendo prosperar. O réu nega a prática da narcotraficância e alega em sua defesa que apenas fugiu ao avistar as viaturas tendo em vista que teria brigado com sua irmã Kelly, no entanto, sequer a arrolou como testemunha para que pudesse ao menos corroborar essa sua narrativa.

Não se está aqui afirmando que a fuga do réu faz presumir sua culpa quanto aos fatos que lhe são imputados. Todavia, ao trazer para o processo fatos e/ou informações novos - notadamente quando constituem tese defensiva - cabe ao acusado fornecer subsídios que confirmem credibilidade àquilo que se afirma.

Por outro lado, o réu também atribui ao vício da irmã Kelly a existência de um pino vazio dentro da residência. Ocorre que, como bem asseverado pelo Ministério Público, o pino vazio não apresentava vestígios de drogas, sendo, portanto, "novo" e dentro da residência também foram apreendidos objetos usualmente utilizados para pesar e embalar drogas para posterior comercialização, como balança, o próprio pino vazio e outros petrechos, o que vinculada a droga encontrada no pasto com o exercício da traficância no imóvel. Além disso, o pino vazio encontrado dentro da residência era de mesma cor e característica dos quais encontrados na sacola que foi visualizada pelo policial militar e encontrada com o cão farejador.

Some-se a isto o fato de que as denúncias apresentadas à Polícia também davam conta de que o comércio era realizado pelo réu, conforme narrativa dos Policiais ouvidos em juízo.

Como se nota, as teses defensivas do réu Cristiano se mostram frágeis e não encontram respaldo na prova produzida sob o pálio do contraditório.

Com efeito, a conclusão que aqui se adota – frise-se, a de que o réu realizava a prática do tráfico – não está respaldada unicamente na apreensão das drogas após a fuga do réu Cristiano pelo pasto. O que evidenciou a destinação dos entorpecentes para o crime de tráfico foi esta apreensão somada a tudo aquilo que foi encontrado na residência do acusado.

Ademais, o fato de os policiais não terem conduzido eventuais usuários que afirmaram ter comprado drogas com os réu também não tem o condão de infirmar a prova do tráfico de drogas. Ora, pelas regras de experiência comum, subministradas pela observância daquilo que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC), é cediço que na grande maioria das abordagens policiais de usuários de entorpecentes dificilmente se obtém a apreensão da droga, seja devido ao fato de o indivíduo já ter consumido a substância, seja pelo fato de ter descartado assim que notou a provável abordagem.

Repito: tais teses não afastam a prova da narcotraficância pelo réu Cristiano.

Em conclusão, a prova do crime de tráfico de drogas, capitulado na norma incriminadora do art. 33, "caput" da Lei 11.343/06, perpassa necessariamente pela análise da destinação das substâncias entorpecentes eventualmente apreendidas, por ocasião da prisão em flagrante ou da busca domiciliar. Neste contexto, mister se faz verificar se em conjunto com as drogas havia outros elementos a comprovar a mercancia dos entorpecentes, a fim de se distinguir tráfico da mera posse para uso (art. 28 da Lei 11.343/06).

No caso dos autos, restou devidamente caracterizada a prática do delito em apreço, porquanto além das substâncias entorpecentes apreendidas, foram encontrados objetos usualmente utilizados para embalar drogas para posterior comercialização, sendo dois rolos de plástico filme, um rolo de papel laminado, uma balança de precisão, um pino (tipo Eppendorf) vazio e R\$ 11,80 (onze reais e oitenta centavos) em moedas diversas, conforme auto de apreensão de fls. 10/11 e fotografia de fls. 14, denotando a traficância.

Entretanto, conclusão diversa é adotada quanto ao crime do artigo 35 da Lei de drogas. Isto porque o próprio tipo penal reclama para sua configuração o envolvimento mínimo de duas pessoas, ou seja, estamos diante de um crime plurissubjetivo, que exige, ainda, a comprovação de estabilidade e permanência para sua exata subsunção.

No caso dos autos, não se desincumbiu a acusação do ônus de comprovar a associação dos irmãos denunciados para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, de modo que a absolvição do réu Cristiano quanto a este delito é medida que se impõe.

Quanto ao crime de tráfico, não restou demonstrada nenhuma excludente de ilicitude, culpabilidade ou punibilidade, ônus que compete à defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal e da pacífica jurisprudência do STJ. Assim, a condenação pelos fatos descritos na denúncia é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena do réu Cristiano Fernando Roque de Souza

Sopesando as circunstâncias do art. 59, do CP, bem como o disposto no 42, da Lei de Drogas, verifico que a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta da ré, deve ser considerada normal, dada a quantidade e a natureza da droga. O acusado não ostenta antecedentes criminais.

Sobre a conduta social e a personalidade do réu não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-las. Os motivos são próprios à espécie. As circunstâncias devem ser consideradas normais. As consequências foram normais. A natureza e a quantidade dos entorpecentes são normais.

Diante destas circunstâncias, na primeira fase, aplico a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que a pena-base permanece inalterada.

Na terceira fase, não há óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º. Isto porque, diferentemente do alegado pelo Ministério Público, não há provas suficientes de que o condenado se dedique às atividades criminosas. Em que pese a existência de outras diligências empreendidas no imóvel com o fim de apurar a prática do crime de tráfico, fato é que não há nenhuma condenação pretérita que permita adotar esta conclusão.

Deste modo, reconheço a incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4º, reduzindo a pena em 2/3 de modo a torná-la definitiva em 01 ano e 08 meses de de reclusão e 166 dias-multa para o crime do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06.

Por não haver elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado, fixo o valor de cada dia multa no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Muito embora o réu tenha permanecido preso provisoriamente, deixo de analisar a detração (art. 387, § 2º, do CPP), em virtude da ausência dos elementos subjetivos da progressão de regime.

Nessa senda, com fundamento no art. 33, do CPC, considerando o montante da pena aplicada e a primariedade técnica do acusado, deverá ele iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva em regime aberto.

É o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 44, do CP: a pena fixada não é superior a 4 anos; o réu não é reincidente em crime doloso; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que a substituição é suficiente.

Deste modo, substituo a pena corporal aplicada ao réu por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo tempo de pena a ser substituída em instituição a ser designada pelo juízo da execução e multa no importe de 01 salário-mínimo à entidade a ser designada pelo juízo da execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR o réu Cristiano Fernando Roque de Souza pela prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", § 4º da Lei 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de de reclusão e 166 dias-multa para o crime do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo tempo de pena a ser substituída em instituição a ser designada pelo juízo da execução e multa no importe de 01 salário-mínimo à entidade a ser designada pelo juízo da execução; bem como para ABSOLVER os réus Luciano Roque de Souza e Cláudio Roque de Souza dos crimes capitulados na inicial, na forma do artigo 386, VII do CPP.

O apenado poderá recorrer em liberdade, um vez que, segundo entendimento recente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial em meio aberto:

(...) A fixação do regime de cumprimento semiaberto revela-se incompatível com a manutenção da prisão preventiva. (HC 181008, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC26-06-2020)

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA clausulado em favor do réu Cristiano Fernando Roque de Souza, encaminhando-se ao Presídio em que se encontra recolhido.

Autorizo, desde já, a destruição do entorpecente que eventualmente tenha sido guardado para novos exames. Decreto a perda, em favor do Estado, dos bens que eventualmente remanesçam apreendidos, oficiando-se para tanto.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso

IV, do Código de Processo Penal, por entender que, no caso do delito de tráfico, dada a sua natureza, incompatível tal estipulação.

Por fim, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, a título de taxa judiciária, observada eventual gratuidade.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários do defensor dativo, nos termos do Convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

P.I.C.

Getulina 16 de maio de 2022

LUIS FERNANDO VIAN

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA